

1502653-66.2020.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas", o chamado tráfico privilegiado, definido pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não mais se enquadra às normas da Lei nº 8072/90.

Contudo, levando em conta a gravidade in concreto do delito praticado, e a necessidade de atentar-se à prevenção geral, uma das funções da pena, deve ser fixado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, . - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1502653-66.2020.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502653-66.2020.8.26.0270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINTON FERNANDO DE ANDRADE GRESKIW e outro

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

WELINTON FERNANDO DE ANDRADE GRESKIW e LUCAS MATEUS DE ALMEIDA, qualificados às fls. 12 e 05, foram denunciados perante este juízo como incurso no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/06 c/c. art. 29 do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 24 de agosto de 2020, às 16h16, na Rua Dirce Camargo de Almeida, nº 590, Vila Santa Maria, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, em concurso de pessoas caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de comércio, 11 porções de COCAÍNA, pesando no total 3,31 (três gramas e trinta e um centigramas), 13 porções de CRACK, pesando no total 8,39 (oito gramas e trinta e nove centigramas), e 18 porções de MACONHA, pesando no total 27,97 (vinte e sete gramas e noventa e sete centigramas), ambo acondicionados e embalados individualmente em invólucro plástico pronto para a venda, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 22/23 e laudos periciais de constatação e definitivo de fls. 25/28, e 100/111, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme decisão de fls. 79/83, foi convertida a prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi

recebida em 09 de março de 2021 (fls. 164).

Os réus apresentaram defesas prévias às fls. 146/149 e 162.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e os réus foram interrogados. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, as defesas dos réus pleitearam sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada parcialmente procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, embora tenha restado devidamente comprovada a localização dos entorpecente, as contradições existentes entre as oitivas dos policiais militares na fase policial e em Juízo, trazem dúvida suficiente a respeito da autoria delitiva do co-réu LUCAS, a ser resolvida em favor do acusado.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 25/28 e 100/111), relatório da autoridade policial (fls. 115/118), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos conforme retro detalhado, restou parcialmente comprovada.

Vejamos.

Foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa.

A testemunha comum RAQUEL ELEONORA DE FREITAS SILVA, policial militar, narrou que foram acionados via COPOM a respeito de uma denúncia de tráfico de drogas na Vila Santa Maria, local bem conhecido por ser ponto de vendas de drogas. A viatura chegou até o local, e um dos réus ao visualizar a viatura jogou algo do lado e o outro saiu andando. Foram até o local em que os réus estavam, perto de um muro, onde foram localizadas as porções de cocaína, maconha e crack. Os réus negaram a propriedade dos entorpecentes. Havia drogas na sacola que o réu Lucas dispensou, mas no muro também havia entorpecentes. Realizou a abordagem dos réus, mas quem localizou a droga foi outro policial. Três viaturas chegaram no local. A respeito do dinheiro localizado com os réus não se lembra o que eles disseram no momento da prisão. Não conhecia os réus de outras abordagens. A denúncia recebida apenas descrevia os dois rapazes, um com a camiseta do São Paulo e outro com a bermuda florida, sem dizer o que cada um faria. O local é conhecido pela prática do tráfico de drogas há tempos. A denúncia foi recebida via COPOM. O Lucas soltou alguma coisa, não se lembra se era uma sacola, mas visualizou o momento em que ele dispensou o objeto. Estava há um quarteirão de distância quando ele dispensou. Bastou ele ver a viatura para dispensar o objeto. Nesse momento eles estavam na parede, conversando. Os réus não eram conhecidos pela prática do tráfico anteriormente. Os réus foram abordados do lado da vila, e não do lado do lixão. Não sabe distinguir se a maioria dos entorpecentes foram localizados na sacola ou no muro.

A testemunha comum PAULO SÉRGIO MOREIRA, policial militar, narrou que no dia dos fatos foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência referente a tráfico de drogas, no Bairro Vila Santa Maria. Um trajava uma camiseta do São Paulo e o outro uma bermuda florida. Ao perceberem a viatura os réus se dispensaram, e ao serem

abordados nada de ilícito com eles foi localizado, mas ao checaram o local em que estavam antes, encontraram uma sacola com cocaína, maconha e crack. Assim, foi dada a voz de prisão aos réus. Estava na primeira viatura, e era o encarregado. Os réus estavam sentados quando chegaram ao local, e ao verem a viatura cada um saiu andando para um lado. Não se recorda quem recolheu as drogas, pois havia várias viaturas empenhadas na ocorrência, uma vez que neste local é comum que a população se revolte contra a presença dos policiais. Não viu nenhum dos réus dispensar os entorpecentes. Não se recorda se havia mais drogas na sacola ou no muro. Não conhecia os réus de outras abordagens. Não se lembra do que os réus disseram no momento da prisão. Foi a primeira ocorrência de tráfico de drogas naquele local. A denúncia descrevia as vestimentas dos réus, que eram idênticas. Na rua havia somente os dois réus. Não se recorda perfeitamente de como os fatos ocorreram. Não me recordo se foi localizado algo no muro em que os réus estavam próximos, devido ao decurso do tempo.

A testemunha de defesa CRISTINA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, declarou que não possui parentesco com nenhum dos dois réus. Presenciou a prisão dos réus, pois estava passando pela rua e viu o Lucas subindo com sua namorada, quando então ele foi abordado pelos policiais. O Wellington estava bem para baixo da rua. Não viu quando as drogas foram localizadas no muro. Viu que a policial feminina entrou em um mato que existe no local e saiu com uma sacola preta na mão. Viu apenas essa sacola preta em que foram encontradas as drogas. O Wellington estava umas 04 ruas para baixo. Nenhum deles estava segurando a sacola. Presenciou a policial feminina localizar a sacola preta, que estava do lado do lixão, e desse lado da rua não há nenhum muro, sendo apenas mato. No momento havia várias pessoas na rua, e os réus não estavam juntos. Quem foi revistado foi o Lucas, a Gabriele, que é sua namorada, e o tio do Lucas. Os policiais não deixaram me aproximar e foram grossos. Havia pelo menos 03 ou 04 viaturas da polícia militar. Não sabe por que a polícia militar vai até o bairro de comboio. O Lucas conhece porque ele trabalha com um sobrinho meu, na batatinha, e conhece Lucas e sua mãe desde muito tempo, quando ele tinha 08 anos. O Wellington conhece de vista, mas nunca soube de nada que pudesse lhe desabonar.

O réu WELINTON FERNANDO DE ANDRADE GRESKIW foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "QUE diante dos advogados Doutor Tiago Alves Pereira, OAB 405110 e do Doutor Bruno Moreira do Amaral, OAB 441493, e diante da inquirição da Autoridade Policial, perguntando se teria sido agredido ou intimidado pelos policiais militares que o detetiveram, respondeu que não, que quanto aos fatos tratados nesses autos, optou em fazer uso de seu direito constitucional de permanecer calado e manifestar-se somente em Juízo" (fls. 12).

Interrogado em Juízo, o réu relatou que no dia dos fatos estava na esquina da rua 11 da Vila Santa Maria, e o Lucas lhe perguntou se tinha maconha para vender, quando então chegou a mulher e o tio de Lucas. Separaram-se e logo após foi abordado pelos policiais, e viu que o Lucas tinha sido abordado na rua de cima, em local distante do local em que estava. A sacola localizada pelos policiais realmente me pertencia, e havia maconha, cocaína e crack. Está com 21 anos e estava vendendo entorpecentes há 03 dias. Resolveu vender entorpecentes porque estava passando por uma situação difícil em casa, junto com sua mãe. É usuário de maconha e cocaína há uns 02 ou 03 anos. Nunca trabalhou com carteira assinada. Saiu com 19 anos da escola. Conhecia o Lucas de vista, mas ele não estava envolvido no tráfico de drogas. Sempre traficava na esquina da rua 11, e vendia do 12:00 às 17:00, e depois à noite também. As drogas estavam em um saco plástico preto transparente, e também no muro. Vendia sozinho as drogas, e não estava ligado a outros traficantes ou organizações criminosas.

O réu LUCAS MATEUS DE ALMEIDA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou: "QUE diante dos advogados Doutor Tiago Alves Pereira, OAB 405110 e do Doutor Bruno Moreira do Amaral, OAB

441493, e diante da inquirição da Autoridade Policial, perguntando se foi agredido ou coagido pelos policiais militares que o detetiveram, respondeu que não e quanto aos fatos objetos desses autos, optou por fazer uso de seu direito Constitucional de permanecer calado e de pronunciar-se somente em Juízo (fls. 05).

Interrogado em Juízo, o réu relatou que viu Wellington na esquina, perguntou se ele tinha maconha para venda, e Wellington o convidou para fumar uma bala de maconha, quando então chegou minha mulher e o tio dela. O Wellington visualizou a viatura e lhe disse para subir para a rua 12, pois ele iria descer. Foi abordado na rua de cima por uma viatura, e dispensou a bala de maconha que havia comprado do Wellington. O dinheiro que estava comigo é do meu trabalho. Já tinha visto o Wellington na rua, e não o conhecia, mas como ali é um ponto de venda de drogas resolveu perguntar se possuía maconha para venda. Trabalha realizando compras e vendas de cavalo para ajudar sua família. Tem atualmente 22 anos. A droga que comprou do Wellington não estava com ele no momento. Wellington desceu e voltou com o entorpecente. Wellington foi abordado pelos policiais em local distante do que eu fui abordado. Não conhecia a policial Raquel Eleanora. A maconha que dispensou estava embalada e pagou 05 reais. Não possui inimizade com o Wellington. Na rua em que foi abordado há casas dos dois lados da rua. Foi abordado em uma esquina, longe do lixão. Wellington estava na rua do lixão quando foi abordado. Não adquiriu a maconha de Wellington não estavam na rua do lixão. Não presenciou os policiais localizarem a sacola com entorpecentes. Quem apareceu com a sacola de entorpecentes foi a policial Raquel Eleanora.

Pois bem, o cotejo dos depoimentos e interrogatórios colhidos em juízo, entre eles, e com o que foi dito por cada um dos ouvidos em solo policial, permite a condenação do co-réu Wellington.

A realidade do encontro da droga é indiscutível, tendo os entorpecentes sido apreendidos e apresentados à autoridade policial. Não é crível que os agentes do estado tenham resolvido incriminar deliberadamente inocentes e, por outro lado, WELLINGTON admitiu em juízo, livre de qualquer coação, que a droga apreendida lhe pertencia, tendo sido encontrada em uma sacola por ele dispensada e no muro próximo do local em que traficava naquela tarde.

Diante da confissão de WELLINGTON, da afirmação de LUCAS de que ali era um ponto de venda de drogas, tanto é que resolveu abordar um desconhecido, que de pronto o convidou para fumar um cigarro de maconha, há nos autos certeza suficiente para a sua condenação pelo crime que lhe imputado.

A mesma certeza, contudo, não encontro com relação ao corréu LUCAS.

Isso porque, em que pese tenham sido uníssonos na delegacia, o que possibilitou inclusive a decretação da prisão preventiva de ambos os acusados, em juízo os policiais militares ouvidos apresentaram contradições. LEONORA disse ter certeza de que viu LUCAS dispensar a sacola, ao passo que PAULO afirmou não ter visualizado quem a dispensou.

É cediço que policiais militares realizam inúmeras diligências e flagrantes semelhantes àquele sobre o qual são ouvidos em Juízo posteriormente, sendo natural que se esqueçam de detalhes ou se confundam quanto a alguma circunstância ocorrida e mencionada na ocorrência. Imprecisões são naturais nos depoimentos das testemunhas, especialmente de policiais que atuam em inúmeras ocorrências criminais envolvendo tráfico.

As discrepâncias, quando incidem sobre aspectos secundários, não têm relevância ao deslinde da causa. Todavia, no presente caso, tendo em vista as flagrantes contradições apontadas, e a negativa do acusado em audiência, somado ao fato de que os policiais narraram que não conheciam os acusados e desconheciam eventual

envolvimento com o tráfico, ao fim da instrução processual não firmei a convicção íntima de que LUCAS praticou o crime pelo qual foi denunciado.

Se a materialidade é certa, a coautoria não restou comprovada.

Em apoio à fundada dúvida cito que mesmo a denúncia recebida de populares não é suficiente para trazer a certeza necessária para a edição do decreto condenatório, isso porque, conforme apontado pelos policiais, a denúncia não descrevia o que cada indivíduo fazia, sendo bem possível que incluiu LUCAS e WELINTON pelo fato de estarem juntos no local, o que foi admitido por ambos.

Para ensejar a condenação, não bastam meros indícios. A prova da materialidade e da autoria da infração penal deve ser concludente, pois só a certeza estreme de dúvida autoriza a condenação no juízo criminal, sendo que, no caso em tela, as provas colhidas falecem de credibilidade.

Nesse sentido, a lição da Professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Maria Thereza Rocha de Assis Moura: "Para constituírem prova segura, os indícios devem ser em número plural, graves e concordantes, e as inferências que outorgam devem ser convergentes ao mesmo resultado, de tal maneira que, em conjunto, mereçam plena credibilidade e levem ao magistrado o absoluto convencimento sobre o fato investigado" (A Prova por Indícios no Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 99).

Na mesma direção, trilha a jurisprudência de nossos tribunais: "Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios não são suficientes para um juízo de condenação" (TRF-2ª Região - AP - Rel. Alberto Nogueira - RT 725/675).

Não se descarta que, quando corroborados por prova produzida sob o crivo do contraditório, os elementos informativos colhidos na fase policial podem embasar a condenação penal. Contudo, nos presentes autos, a prova produzida em Juízo é vaga e insuficiente para a condenação de LUCAS.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação de WELINTON, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas aos autos fls. 37/42, o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes após a atingir a maioridade. Não há elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais. Não obstante, dada a natureza dos entorpecentes encontrados com o réu, entre eles o crack e a cocaína, de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo unitário

Na segunda fase de dosimetria, não incidem agravantes e estando presente a atenuante da menoridade relativa, retorno a pena para o mínimo legal cominado.

Não há causas de aumento.

O réu preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Considerando o até aqui já apreciado para fixação de sua pena, a redução deve se dar na expressão próximo da máxima (3/5). Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e

pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando o realinhamento da posição jurisprudencial (Tema 600), após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado decidiu cancelar a súmula 512 - STJ, editada em 2014 (Súmula 512 - "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas", o chamado tráfico privilegiado, definido pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não mais se enquadra às normas da Lei nº 8072/90.

Contudo, levando em conta a gravidade in concreto do delito praticado, e a necessidade de atentar-se à prevenção geral, uma das funções da pena, deve ser fixado o regime semiaberto.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade: Embora no HC nº 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da vedação da conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos que constava dos arts. 33, §4º e 44 da Lei 11.343/06, entendo que a fixação de penas alternativas para o condenado pelo crime de tráfico fica reservada a hipóteses excepcionabilíssimas, em que as circunstâncias objetivas da conduta foram bastante favoráveis e as condições subjetivas do acusado passam confiança ao juízo de que o réu irá se afastar das drogas e as restrições impostas serão cumpridas a contento.

Assim, sequer é suficiente que a pena tenha sido fixada no mínimo, é preciso que fique comprovada (para além da presunção de inocência) a total inofensividade do agente. De outra forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). E, ausentes todos os requisitos para a aplicação do benefício, incabível a substituição.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 77, caput, e inciso I e II do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu WELINTON FERNANDO DE ANDRADE GRESKIW, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e, em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 02 (dois) anos reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, e para absolver LUCAS MATEUS DE ALMEIDA da mesma acusação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Inaplicável, no caso, o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar a real situação processual do acusado.

A alteração do regime inicial deve obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há informações a respeito do bom comportamento do condenado neste momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal.

Poderá o acusado apelar em liberdade, se assim o desejar, considerando que a ele foi concedida a liberdade provisória no curso do processo.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art.

63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Fixo os honorários advocatícios ao dativo em 100% da tabela vigente.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA